

1500279-89.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... ao denunciado. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - DA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. Excelência, de início, em relação ao crime de tráfico de drogas, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz mister um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um édito condenatório. Não é, todavia, o que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500279-89.2022.8.26.0599 - Controle nº 2022/000223

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2051676/2022 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME SANTOS

Aos 01 de agosto de 2022, às 16:00h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao disposto no Provimento CSM 2651/2022, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. MARIANA BERNARDES ANDRADE E SILVA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: GUILHERME SANTOS - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: Representante da empresa ND Telecom - T.F.M.L. - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC JAMES BATISTA TAVARES - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC PRISCILA BERTOLOZZI CEREJA - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos da representante da empresa ND Telecom, T.F.M.L. e da testemunha PC JAMES BATISTA TAVARES.

Nos termos do artigo 217 do C.P.P., a pedido da representante da empresa ND Telecom, T.F.M.L., o seu depoimento foi colhido na ausência do réu.

Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha PC PRISCILA BERTOLOZZI CEREJA, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha PC PRISCILA BERTOLOZZI CERREJA, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Após, o réu GUILHERME SANTOS foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foram apresentadas alegações finais, as quais foram gravadas através do sistema de mídia digital, disponibilizadas estas no Sistema SAJ.

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 180 do Código Penal, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao denunciado. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - DA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. Excelência, de início, em relação ao crime de tráfico de drogas, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz mister um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um édito condenatório. Não é, todavia, o que ocorre na hipótese dos autos. Nesta data, a Senhora Tamiris, representante da empresa-vítima, declarou que é gerente da empresa ND Telecom. O funcionário Cristian, no dia 17 de fevereiro, não apareceu para trabalhar e não atendia o telefone. Pelo rastreador do veículo, mostrava que ele utilizou o automóvel a noite toda, o que é proibido pela empresa. E o endereço do automóvel era diferente da residência do réu. Quando pediu para outros funcionários irem até o local onde o carro estava, ele estava abandonado e vários objetos estavam faltando, inclusive o celular. Pegaram o veículo e, no dia seguinte, o Cristian disse que o celular estava com um amigo, mas não disse quem era a pessoa. Por conta disso, informaram que o aparelho seria rastreado e que o funcionário seria desligado. Posteriormente, o aparelho foi recuperado porque encontraram a localização do aparelho e ele foi localizado na posse de outra pessoa. Reconheceram o aparelho pela capa e pelo número do IMEI. Acredita que encontraram entorpecentes também com essa pessoa. O Cristian não disse como passou o celular para um terceiro e nem o motivo porque fez isso. A testemunha James, Policial Civil, declarou que uma funcionária de uma rede de telecomunicações procurou a equipe afirmando que seu funcionário teria mencionado algo sobre roubo de um celular e de outros equipamentos. Ela confeccionou o BO, porém, como a história estava esquisita, lavraram como apropriação indébita. A funcionária disse que o celular da empresa estava apontando, no serviço de localização, um endereço próximo ao Bar do Pantera. Foram ao local e fizeram uma "campana", oportunidade na qual visualizaram uma aglomeração típica de tráfico de drogas (várias pessoas chegavam e saíam). Fizeram a abordagem de vários indivíduos, porém, o funcionário da empresa tinha um sistema um pouco diferente de rastreamento e conseguiram identificar que ele estava na posse do réu. O acusado disse que tinha recebido o aparelho de outro rapaz. O IMEI era o mesmo que constava no Boletim de Ocorrência. Em busca pessoal, encontraram 42 porções de crack com o acusado, além de uma pedra um pouco maior. O acusado confessou informalmente que traficava entorpecentes e disse que um rapaz que trabalha numa empresa de telefonia trocou o celular, além de um veículo e uma escada por drogas. Ele disse que questionou o funcionário se havia algum problema com o aparelho, mas o funcionário disse que não. Não conhecia o acusado antes dos fatos. O local é ponto de tráfico. A funcionária da empresa fez um rastreamento do aparelho em tempo real e ele começou a tocar, porém, não se recorda se ele estava ligado. Ele disse que recebeu um carro, um celular e uma escada, porém, acha que o veículo foi localizado e apreendido em um dia anterior

pela PM. Acredita que o réu teria trocado os bens por 10 porções de crack, mas não se recorda totalmente. O acusado disse que não participou de nenhum roubo. Ele reconheceu na Delegacia o funcionário da empresa de telefonia que entregou os bens ao acusado. Não lembra se o réu disse há quanto tempo estaria traficando. O réu, em interrogatório, declarou que o Cristian apareceu e ofereceu o celular, o carro e uma escada ao réu e a seu amigo. O amigo do acusado ficou com o carro e a escada e o réu aceitou o celular em troca de dez pedras de crack. Estava com 42 porções de crack. Indicou aos Policiais onde a droga estava. "Segurou" as pedras porque sua cunhada estava grávida e o entorpecente estava na bolsa dela. O celular era do réu. Estava vendendo drogas, mas os entorpecentes achados não eram do réu. Tinha começado a vender drogas fazia aproximadamente 04 dias. Comprou o celular no dia que começou a vender. O seu amigo comprou as outras coisas uns três ou quatro dias antes do réu ser preso. Não sabia que o Cristian era um "noia", nunca tinha visto ele antes. Perguntou para ele se o celular tinha algum problema, mas ele disse que era dele. Atualmente, está trabalhando em lava-rápido. Não segurou o BO do seu amigo na Delegacia, pois ele foi preso alguns dias antes dos fatos. Quando seu amigo pegou o carro, estava junto com ele. Estava vendendo drogas há aproximadamente quatro dias. Em primeiro lugar, quanto à confissão (ainda que parcial) do réu, verifica-se que ela possui valor probatório relativo e deve ser corroborada pelo restante do conjunto probatório, o que não ocorreu na espécie. Dessa forma, em relação ao delito de tráfico de drogas, como se observa, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, as quais, todavia, devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que não pretende a defesa desqualificar a nobreza ou a honestidade da instituição responsável pela segurança pública do Estado, muito menos negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem, em juízo, a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a defesa, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras dos policiais como fundamento para uma condenação, verbis: "Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger." (TJSP – 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin – j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito das declarações dos Policiais, nenhum ato de comércio foi visualizado antes da abordagem do acusado e não foram apresentados outros indivíduos como testemunhas presenciais dos fatos e/ou possíveis compradores das substâncias entorpecentes. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Portanto, diante das provas produzidas, a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO

NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI nº 11.343/06. Caso este E. Juízo entenda não ser possível acolher o pleito absolutório, postula-se, então, pela aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. É que, na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado é primário e tem bons antecedentes. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido, apenas em função da quantidade de entorpecentes que fora apreendida, que, aliás, nem mesmo se mostra elevada, na hipótese. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu, à vista da absoluta primariedade do denunciado. Além disto, o Decreto 5.015/04, que promulga a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, define, em seu artigo 2º, o conceito de organização criminosa: “Artigo 2º – Terminologia. Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: a) “Grupo criminoso organizado” - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material; (...). Do cotejo do texto legal acima citado, é evidente que não se configurou uma organização criminosa. Assim, quanto a “integrar organização criminosa”, é possível afirmar que a intenção do legislador foi vedar a aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo àquele que é membro de organização criminosa, ou seja, possui vínculo de forma ativa e permanente com a mesma, além de grande envolvimento com seus mecanismos e pessoas, o que, à evidência, não ocorre na hipótese em testilha. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida)” (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

DO CRIME DE RECEPÇÃO – DA POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL.

Por sua vez, Excelência, quanto ao delito de receptação, é cediço que o dolo é elemento indispensável para a configuração do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Como desdobramento de tal premissa, surge a imprescindibilidade de a acusação comprovar a tipicidade subjetiva que atribui ao acusado – o que inclui a comprovação da vontade e da consciência de praticar a conduta ilícita. Não há nos autos, contudo, qualquer prova de que o réu tivesse ciência de que o celular apreendido fosse fruto de um crime. Sabe-se que, atualmente, o direito penal, acompanhando a evolução da sociedade de risco, caminha de forma expansiva, incidindo sobre áreas que normalmente não ficavam ao alcance deste ramo jurídico, sofrendo, outrossim, mutação quanto a diversos preceitos basilares característicos do direito penal clássico. Mas, mesmo neste contexto atual, não é possível a punição descolada do princípio da culpabilidade (*nullum crimen, nulla poena sine culpa*), sob pena de se admitir a odiosa responsabilidade objetiva no campo criminal. Por isso, Excelência, diante da verdade material colhida nestes autos, fica evidenciado que o réu não tinha plena consciência de que o telefone celular

era objeto de crime anterior, pois não há nenhum elemento probatório que indica esta situação, pelo que não restou configurado o elemento subjetivo do crime de receptação, o dolo, não sendo possível, pois haver a condenação, eis que não há responsabilidade objetiva no direito penal. Anota-se, também, que, segundo a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Código de Processo Penal, no sistema acusatório brasileiro compete à acusação a demonstração dos elementos caracterizadores do delito, em especial a tipicidade subjetiva, de modo que não compete ao acusado demonstrar que não tinha ciência da origem ilícita do bem ou descaracterizar qualquer “presunção” neste sentido, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Destarte a absolvição do acusado é medida que se impõe, nos termos do art. 386, III ou VII, do CPP. Caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, pugna a defesa, então, pela DESCLASSIFICAÇÃO PARA A RECEPTAÇÃO CULPOSA (art. 180, parágrafo terceiro, do Código Penal), vez que, no máximo, caso se entenda que ele efetivamente recebeu o bem em questão, é possível dizer que foi negligente ao recebê-lo, devendo, portanto, ser a conduta ajustada ao tipo penal previsto no artigo 180, § 3º, do CP, com as consequências legais. Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, e que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, são absolutamente favoráveis ao acusado; (ii) na segunda fase da dosimetria, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e, quanto ao tráfico de drogas, da confissão espontânea (ainda que extrajudicial); (iii), a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iv) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para o cumprimento da pena, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ e, ainda, em razão do disposto no art. 387, § 2º, do CPP; (iv) a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em razão da Resolução do Senado nº 5 de 2012 e das inúmeras decisões do Supremo (Plenário e Turmas), reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.434/06, que continha tal vedação (v.g. STF – Segunda Turma - HC nº 110.920/MG – rel. Min. Carmen Lúcia – j. 19/02/2013); (v) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento, a decretação da prisão preventiva”.

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

“Vistos.

GUILHERME SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 180 do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 22 de fevereiro de 2022, por volta das 11h, na Rua Nelson Camponês do Brasil, nº 22, Bairro Piracicamirim, nesta cidade e comarca de Piracicaba, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 42 (quarenta e duas) porções de cocaína, na forma de “crack”, com peso de 12,35g, além de outra porção maior da mesma droga “crack”, com peso de 7,71g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, também, que, entre os dias 19 e 22 de fevereiro de 2022, nesta cidade e comarca, o réu recebeu, em proveito próprio (e no exercício do tráfico de drogas), o aparelho de telefone celular marca “Motorola”, modelo “Moto Play”, avaliado em R\$ 1.299,00, de propriedade da empresa ND Telecom, representada por Tamires Fernanda Moraes Leite, sabendo tratar-se de produto de crime.

Narra a denúncia que policiais civis investigavam um crime de apropriação indébita, em que a pessoa de Cristian da Rocha Martins, simulando ter sido vítima de roubo, teria se apropriado de um veículo, uma escada e um aparelho celular de propriedade da empresa em que trabalhava (ND Telecom) – fato apurado em procedimento próprio.

Durante as investigações e, mediante rastreamento do aparelho celular apropriado, os policiais o localizaram no endereço mencionado no item "1" supra, onde se situa o estabelecimento comercial denominado "Bar do Pantera", conhecido ponto de tráfico de drogas. Os policiais, então, foram até o local, deparando-se com o acusado na posse do aparelho celular produto de crime, sendo que, realizada revista no réu, os policiais encontraram com ele as 42 pedras de "crack", além de outra porção maior da mesma droga. Indagado, o acusado confessou a prática do tráfico (especificando que vendia cada pedra a R\$ 10,00), informando ainda que recebera o aparelho celular produto de crime da pessoa que reconheceu como sendo Cristian da Rocha Martins, tendo este entregue para o acusado o aparelho celular (além do veículo e de uma escada de propriedade da empresa) como forma de pagamento pela aquisição de 10 pedras de "crack". Interrogado na delegacia de polícia, o réu confirmou a versão apresentada pelos policiais (fls. 09).

O réu foi notificado nos termos do art. 55 e seguintes da lei 11.343/06 (fls. 122) e apresentou defesa preliminar (fls. 101/104), seguindo-se a decisão que recebeu a denúncia (fls. 124/127).

Designada audiência de instrução, foram ouvidas a representante da vítima e duas testemunhas arroladas na denúncia. Após, foi interrogado o acusado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do crime de tráfico restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, pelas fotografias de fls. 19/22 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 157/159, que trouxe resultado positivo para cocaína. A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado confessou a prática do tráfico e negou a receptação. Declarou que morava no Bairro Monte Líbano e, na data dos fatos, estava na casa de seu irmão, na Rua Nelson Camponês do Brasil, 122, Piracicamirim quando foi abordado por policiais civis e cientificado de que que um aparelho celular, produto de apropriação indébita, estava naquele local, conforme posicionamento indicado pelo rastreador do aparelho. Disse que, imediatamente, entregou o aparelho Motorola, modelo Motoplay, cor azul/verde, que estava em seu poder. Aduziu que, realizada busca pessoal, foram encontradas em seu poder 42 (quarenta e duas) pedras de "crack" e uma porção, em pó, da mesma substância. Narrou que, ao ser questionado acerca da origem do celular, informou que recebeu o aparelho em troca de 10 (dez) pedras de "crack", assim como uma escada e um carro de empresa de pessoa que desconhecia. Alegou que, antes de entregar os entorpecentes, questionou o usuário sobre a procedência do celular, perguntando "se não teria B.O. para ele? Se não seria um aparelho roubado", tendo o indivíduo negado a origem ilícita do bem. Negou ter roubado os objetos e, após consultar o álbum digital de fotografias da Delegacia, reconheceu Cristian da Rocha Martins como sendo o indivíduo que teria trocado o telefone, carro e escada pelos entorpecentes. Admitiu a posse dos entorpecentes apreendidos e relatou que vendia as peças de "crack" por R\$ 10,00, cada uma (fls. 09)

Em juízo, apresentou versão parcialmente diversa. Disse que um sujeito apareceu com um carro e uma escada, que um amigo seu comprou. Afirmou que esse sujeito lhe ofereceu o celular, tendo perguntado para o rapaz se não era "BO", tendo ele afirmado que o celular era dele e que trabalhava. Então, deu dez pedras de "crack" para ele. Disse que o carro foi apreendido um antes de sua abordagem. No dia seguinte, os policiais o detiveram. Afirmou que os policiais também apreenderam 42 pedras de "crack", que estavam na bolsa da sua cunhada e não lhe pertenciam, mas admitiu a propriedade do entorpecente porque ela estava grávida. Asseverou que estava vendendo drogas, mas aquelas porções apreendidas não lhe pertenciam. Disse que tinha começado a praticar a venda quatro dias antes e, no primeiro dia, recebeu aquele celular. Aduziu que o sujeito que lhe entregou o celular e vendeu o carro para o seu amigo, era um nória. Acrescentou que o celular tinha adesivos da empresa. A confissão extrajudicial, porém, foi corroborada pela prova produzida.

O policial civil James relatou que a gerente de uma rede de telecomunicações lhes procurou dizendo que um funcionário teria comunicado roubo de veículo, aparelho celular e materiais, mas ela achou a história estranha e a ocorrência foi registrada como de apropriação indébita. Atestou que a gerente rastreou o celular e foi possível apurar que o aparelho estava perto do bar do Pantera, local conhecido como ponto de tráfico. Atestou que uma equipe foi ao local e verificou situação típica de tráfico, razão pela qual fizeram a abordagem. Afirmou que um técnico fazia rastreamento em tempo real e acionava um mecanismo de alerta, sendo possível constatar que o aparelho estava na posse do réu, pois começou a tocar uma sirene. Indagado, o réu admitiu que tinha recebido o celular e verificaram, pelo IMEI, que era o celular da empresa. Disse que fizeram busca pessoal e encontraram 42 porções de crack e uma pedra maior da mesma droga. Na sequência, o réu falou que a droga era sua e que vendia, sendo que um rapaz de uma empresa de telefonia foi até ele e deixou o carro, o celular e uma escada em troca da droga, tendo ele até perguntado para o funcionário se o celular era "BO", ao que o funcionário falou que não. No mesmo sentido o depoimento da policial civil Priscila, ouvida a fls. 05. A confissão prestada em sede policial, enfim, foi corroborada pelos demais elementos de prova, não há como desprezá-la.

A propósito do tema os seguintes julgados:

Processo penal. Prova. Confissão extrajudicial. Posterior retratação judicial.

Eficácia probatória da confissão realizada perante a autoridade policial. A confissão vale, não pelo lugar onde é prestada, mas por seu próprio teor, sempre que confirmada pelo restante do conjunto probatório. (TJSP, 871392520098260050 SP 0087139-25.2009.8.26.0050, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 09/02/2012, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/02/2012).

"HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMARAM A CONVICÇÃO DO JULGADOR.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Não configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, corroborada por depoimentos colhidos na fase instrutória. 2. Embora não se admita a prolação do édito condenatório com base em elementos de convicção exclusivamente colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular e o Tribunal de origem apoiaram-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do devido processo legal. (...) (STJ, 115255 MS 2008/0199821-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/05/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2010).

"Não se pode perder de vista que, sem razão extraordinária, não é comum alguém mentir contra si próprio. E na espécie, não se vislumbram fatos que pudessem implicar no reconhecimento de uma falsa confissão na polícia. De mais a mais, insista-se, a confissão naquela fase merece eficácia probatória, porque crível e verossímil, fruto da clara correlação entre os testemunhos, tudo a permitir a responsabilização penal do recorrente. De mais a mais, a confissão policial pode prevalecer à retratação judicial, quando harmônica com o restante da prova, uma vez que aquela vale pelo grau de credibilidade que lhe seja inerente e não pelo local em que é colhida". (Revisão n.º 297.262/1, TACRIM, 4o Grupo de Câmaras, Relator: Luiz Ambra, RJTACRIM 35/497).

Enfim, o fato de os policiais civis terem apreendido 42 pedras de "crack" e uma porção maior da mesma droga, em pó, na posse do acusado, que confessou a propriedade dos entorpecentes e a traficância, conduzem à certeza quanto à autoria e a destinação do entorpecente ao comércio ilícito.

Consigno que, a quantidade de entorpecentes apreendida e a forma como estavam acondicionados, aliados ao local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, deixam mesmo evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia.

Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 00038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, "caput", cabendo anotar que, para sua configuração, não se exige qualquer ato de venda, bastando, como no caso em tela, que o agente traga consigo substância entorpecente.

Também ficou configurado o delito previsto no art. 180, "caput", do Código Penal. A materialidade do crime de apropriação indébita mencionado na denúncia vem comprovada pelo boletim de ocorrência entranhado a fls. 12/15, que faz referência ao RDO 515/2022, no qual foi noticiada a subtração ocorrida no dia 17.02.2022, do celular Motorola Motoplay, verde, IMEI 352.234.670.658.979/352.234.670.658.987, pertencente à empresa ND Telecom.

Ademais, ouvida em juízo, a representante da vítima confirmou a subtração. Disse que Cristian, funcionário da empresa, não apareceu para trabalhar e não conseguiram contato com ele. Porém, o rastreador apontava que ele tinha usado o carro da empresa durante toda a noite e o veículo estava em local diverso de onde deveria estar, que era a casa dele. Informou que lograram verificar que o veículo fora abandonado numa praça e o recuperaram, mas faltavam alguns materiais, tais como escada, furadeira e o celular da empresa. Atestou que, no dia seguinte, Cristian apareceu na empresa, falou que realmente tinha usado o veículo para fins particulares e que o celular estava na posse de terceira pessoa, mas ele não conseguia reaver. Então, informou-o de que o celular era rastreável e fez o BO, indicando todos os bens que não foram recuperados. Acrescentou que o celular estava ligado e foi localizado em poder de terceira pessoa, aduzindo que, salvo engano, havia droga junto, mas Cristian não falou para quem entregou o aparelho, nem em que condições.

Assim, está devidamente confirmada a origem ilícita do bem.

E não há dúvidas de que o réu o recebeu, em proveito próprio, eis que celular foi apreendido em seu poder (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 16/17).

Também não restou qualquer dúvida de que ele conhecia a procedência criminosa da coisa, fato indispensável para a configuração do tipo descrito no art. 180, "caput", do Código Penal.

Conforme já decidiu o E. Tribunal de Alçada Criminal, "a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração" (JUTACRIM 96/240).

Nesse mesmo sentido o seguinte julgado: "Tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí por que a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente" (JUTACRIM 83/242).

Ora, o próprio acusado admitiu que recebeu o celular no exercício da traficância, de um usuário de drogas, que, no mesmo contexto, teria vendido um veículo de uma empresa, com adesivos da firma, não sendo crível que desconhecesse sua origem ilícita.

Há, enfim, elementos concludentes e seguros que conduzem à certeza de que o réu era conhecedor da origem criminosa da res que portava, sendo descabida a desclassificação para a modalidade culposa.

A propósito do tema vale citar, ainda, trecho do julgamento da Ap. 1.012.873-6, 11a. Câm., de que foi relator o Juiz Renato Nalini:

"Exigir-se elemento probatório mais vistoso do dolo do receptador, equivale a deixar sem cobra essa cômoda situação daqueles que, por cupidez, aceitam os ganhos da ilicitude e nada respondem perante a Justiça (...). O dolo, na receptação,

deriva de uma série de circunstâncias, nunca existindo prova explícita, ressalvada a hipótese de confissão integral do receptor. Este é o último elo na cadeia da criminalidade contra o patrimônio (...). Resta invulnerável, imune à responsabilização, diante da dificuldade na apuração de sua intenção criminosa (...).”.

Convém lembrar, por fim, que a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, verifico que o réu é primário. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo as penas-base no mínimo legal, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo, para o crime de tráfico, e, em um ano de reclusão e dez dias-multa, no valor unitário mínimo, para o crime de receptação.

Não há circunstâncias agravantes e, porque fixadas as penas no valor mínimo legal, nenhuma atenuante pode reduzi-las.

Não há causas de aumento. De outro lado, o réu não tem antecedentes criminais e não há indícios de seu envolvimento com o crime organizado. Assim, reduzo a pena do tráfico em dois terços, nos termos do art. 33, § 4º, e 42, ambos da Lei nº 11.343/06, totalizando um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.

Somando-se as penas, na forma do art. 69 do Código Penal, resultam dois anos e oito meses de reclusão e cento e setenta e seis dias-multa.

Quanto à substituição da pena corporal por restritiva de direitos, muito embora, em tese, possível, comungo do entendimento de que a benesse é incompatível ao condenado por crime de tráfico, não em função de impeditivo legal, mas pela periculosidade social presumida, incompatibilizando o autor de delito dessa natureza com atividades comunitárias ou assistenciais, na medida em que o recoloca em contato direto com grupo suscetível ao seu assédio (cf. Apelação nº 0004555-80.2014.8.26.0451, Rel. Des. Augusto de Siqueira, j. 26.01.17).

Observo que o art. 44 do Código Penal, em seu inciso III, expõe elementos a serem considerados quando da substituição da pena corporal por restritiva de direito, consignando, ao final, a necessidade de que a substituição seja “suficiente”.

Na hipótese, a substituição é medida insuficiente para a prevenção do abjeto comércio que se difunde e fomenta a delinquência no país, sendo, portanto, de acordo com a regra prevista no inciso III do referido diploma penal, imperiosa a manutenção da pena privativa de liberdade.

Some-se a isso que o tráfico foi praticado em concurso com o crime de receptação. Tenho, por conseguinte, que a substituição realmente não é adequada para a reprovação e prevenção do crime.

No que tange à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, consigno que, com a edição do Novo Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal em razão do disposto pelo art. 3º do Código de Processo Penal, estabeleceu-se a necessidade de os juízes observarem o precedente ao julgar determinada matéria.

Com efeito, o art. 926 do Código de Processo Civil dispõe: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”.

Já o art. 927 do mesmo código estatui: “Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”.

Prosseguindo, o art. 928 estabelece: “Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: I - incidente de resolução de demandas repetitivas; II - recursos especial e extraordinário repetitivos”.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.118.533/MS, firmou entendimento no sentido de que o denominado tráfico

privilegiado de drogas não tem natureza hedionda.

Nesse contexto, anotou a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no julgamento do Recurso Especial paradigma 1.329.088/RS, referente ao Tema 600 do Superior Tribunal de Justiça: "É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalícia, sob o rito dos recursos repetitivos".

E, de forma unânime, decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela interpretação da lei federal e sua correta aplicação, acompanhando o entendimento consolidado pela Corte Suprema, que o tráfico de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06) não é crime equiparado a hediondo, cancelando a súmula 512, editada em 2014 após o julgamento do REsp 1.329.088 sob o rito dos repetitivos.

Enfim, estando pacificada nas Cortes Superiores a não hediondez do tráfico privilegiado, sendo o réu primário e imposta pena inferior a quatro anos, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Porém, porque foi beneficiado com a liberdade provisória no curso do processo e porque não sobrevieram motivos a ensejar custódia cautelar, poderá recorrer em liberdade.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu GUILHERME SANTOS, qualificado nos autos, por incurso no art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 e no art. 180, "caput", do Código Penal, à pena de dois anos e oito meses de reclusão e cento e setenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixado regime inicial aberto.

Oportunamente, expeça-se mandado de prisão e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU e DEFENSOR foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida.

A seguir, pela MMª. Juíza foi deliberado o seguinte:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data.

.

2) Tendo em vista a fixação de regime aberto para cumprimento da pena, expeça-se termo de advertência em apartado concomitantemente com mandado de prisão de regime aberto.

3) Cumpra-se a Res. 09/85 do TJSP, oficiando-se ao IIRGD, SARC e TRE.

4) Expeça-se guia de recolhimento definitiva.

5) Tratando-se de multa cumulativamente aplicada, providencie-se inserção do valor atualizado no sistema informatizado, consignando-se o montante de R\$7.478,82, equivalente a 233,93 UFESPs, oportunamente abrindo-se vista ao Ministério Público para as providências cabíveis. Ato contínuo, providencie-se o lançamento da movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal", nos termos do Art. 480, caput, das NSCGJ.

6) O réu foi assistido por Defensor Público, logo, está isento das custas processuais.

7) Regularizados os autos, archive-se com a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", nos termos do Art. 480, §1º, das NSCGJ. .

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado

eletronicamente pela MM^a. Juíza de Direito da 4^a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo
JUIZA DE DIREITO
[Assinado eletronicamente]